

1507190-03.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - Receptações e tráfico de drogas - Recurso defensivo - Preliminar de violação ao princípio do juiz natural - Inocorrência - Designação prévia, dos magistrados, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça - Preliminar de nulidade ab initio, por violação a domicílio - Entrada franqueada - Tráfico de drogas - Delito permanente - Se aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507190-03.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507190-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL OLIVEIRA DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

DANIEL OLIVEIRA DOS REIS, vulgo "Daniel Banguelo", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 23 de março de 2021, por volta das 16h00min, em ocasião de calamidade pública, na Rua Carolina Guedes, 336, São Domingos, nesta cidade e comarca da capital, mantinha em depósito e guardava, droga, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um "tijolo" de maconha com peso líquido de 815.5g (oitocentos e quinze gramas e cinco decigramas), além de 59 (cinquenta e nove) cigarros, contendo a mesma substância, com peso líquido de 47.8g (quarenta e sete gramas e oito decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, (fls. 63/65).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01) e sua prisão, convertida em preventiva (fls. 46/50).

A denúncia foi recebida (fls. 78/80).

O réu foi citado (fls. 127), apresentando Defesa Prévia (fls. 110/109), sendo mantido o recebimento da denúncia e concedida liberdade provisória (fls. 128).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu

(fls. 151/152).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia.

Foi juntada a mídia de fls. 155.

A Defesa, por sua vez, alegou ilicitude da prova e pleiteou a improcedência da ação. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação da pena no mínimo legal o afastamento da agravante mencionada na denúncia e o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º da lei mencionada, aplicando-se regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 157/163).

O Ministério Público se manifestou às fls. 167 sobre a mídia juntada pela defesa. É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de fls. 11/12, laudo de constatação (fls. 22/25) e laudo definitivo toxicológico (fls. 148/150), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O réu negou a prática do tráfico. Afirmou que os cigarros de maconha eram para seu consumo, mas negou a propriedade do tijolo encontrado. Disse que não conhecia os policiais e não os autorizou a entrar em sua casa (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial militar Dirceu Nascimento da Silva narrou, em suma, que estavam realizando patrulhamento na região de Pirituba, quando uma informante relatou que, no local dos fatos, o réu estaria traficando drogas. Foram até o local, um quintal com várias residências. O acusado correu ao avistar os policiais. Abordado, o acusado confessou a traficância e relatou que na sua casa, havia cigarros já embalados para a venda. Na casa do réu, encontraram os cigarros e mais um tijolo de maconha. O acusado nada falou sobre o tijolo mencionado. Não conhecia o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Renaud Fernando Dias de Campos, também policial militar, informou, em síntese, que estavam em patrulhamento pela região, quando receberam informações anônimas de que o acusado estava traficando no local descrito na denúncia. No local, se depararam com o portão aberto e quando ingressaram, o acusado fugiu para os fundos da residência. Com o réu, nada encontraram, mas ele confessou a prática da traficância e os levou até sua residência, onde encontraram cigarros e um tijolo de maconha. O réu não mencionou há quanto tempo traficava. Não se lembra se apreenderam dinheiro. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos das testemunhas, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos. Destarte, prevalecem os testemunhos por elas prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidas de depor ou eram testemunhas suspeitas, possuindo força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, negando a propriedade do tijolo e que confessou a traficância, não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente. Pelo contrário, mencionou não conhecer os policiais.

Ademais, há que destacar que não se vislumbra ilicitude na prova obtida com a busca e apreensão do entorpecente realizada na residência em questão, pois não há, nos autos, provas de que as filmagens de fls. 155 referem-se a residência do acusado ou

as fatos ora apurados.

Destarte, de rigor se concluir pela validade da prova, embora não comprovado que o réu consentiu o ingresso dos policiais em sua casa, pois a Constituição Federal no artigo 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio, mas ressalva o ingresso, sem consentimento do morador, em caso de flagrante delito. Assim, observados os requisitos constitucionais, diante o flagrante de crime de tráfico no caso em tela, crime este de natureza permanente.

No caso em tela, pelo que se depreende dos autos, os policiais civis já investigavam o local descrito na denúncia, em razão de informações de o réu estava traficando. Assim, presentes justa causa e urgência para o ingresso dos policiais no interior da residência, onde, aliás, encontraram expressiva quantidade de entorpecentes.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - Receptações e tráfico de drogas - Recurso defensivo - Preliminar de violação ao princípio do juiz natural - Inocorrência - Designação prévia, dos magistrados, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça - Preliminar de nulidade ab initio, por violação a domicílio - Entrada franqueada - Tráfico de drogas - Delito permanente - Se aos policiais não foi dado o ingresso à residência, havia permissão constitucional para a penetração, porquanto o delito permanente tem sua consumação protraída no tempo - Preliminares afastadas - No mérito, materialidades e autorias todas comprovadas - Ciência da origem ilícita dos bens que se comprova pela atitude e natureza da res - Tráfico mais que evidenciado - Elevadíssima quantidade de entorpecente, com petrechos para venda - Pena não modificada, para o tráfico, em virtude de erroneamente se ter aplicado a causa de diminuição especial, para indivíduo dedicado às atividades criminosas - Preliminares afastadas e recursos não providos. (TJ-SP - APL: 00442611420148260114 SP 0044261-14.2014.8.26.0114, Relator: Alberto Anderson Filho, Data de Julgamento: 28/07/2016, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/08/2016) (grifo nosso)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - Ilicitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório - Apreensão de considerável quantidade de droga (03 tijolos de maconha, com peso líquido de 684,60 gramas), além de dinheiro e uma balança de precisão - Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares. Quantidade e natureza do entorpecente e mau antecedente (1/6) - Compensação da agravante do artigo 61, II, j, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública) com a atenuante da confissão espontânea. Reincidência específica (1/6) - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III)- Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei - Prequestionamento - Apelo desprovido (TJ-SP - APR: 15018282120208260530 SP 1501828-21.2020.8.26.0530, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 23/04/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifo nosso)

Destarte, não se verifica, no caso em tela, desrespeito ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria, fixou tese nos seguintes termos:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de

responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, “manter em depósito” e “guardar”, para fins de tráfico, “Tetrahydrocannabinol”, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Destarte, os depoimentos colhidos, e não só a quantidade de droga, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar o pedido formulado pela a Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não é caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, ausentes atenuantes. Assim, mantenho a a pena no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão penal, para CONDENAR o réu DANIEL OLIVEIRA DOS REIS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no patamar estabelecido. A pena privativa de

liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada.
Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.
Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.
P.I.C.
São Paulo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA